

1500893-41.2021.8.26.0628
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: BRUNO CORTINA CAMPOPIANO
Comarca: Itapecerica da Serra
Foro: Foro de Itapecerica da Serra
Vara: 3ª Vara
Data de Disponibilização: 18/07/2022
... 9.6.2015).

Vale ressaltar que a tortura e o tráfico de entorpecentes receberam o mesmo tratamento pelo constituinte originário (art. 5º, XLIII, CF/88).

Não há qualquer razão, portanto, para conferir ao condenado por tráfico tratamento mais benevolente do que o concedido ao apenado pelo delito de tortura -- sendo conveniente lembrar, aliás, que o crime de tortura, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

3ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra - SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500893-41.2021.8.26.0628 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500893-41.2021.8.26.0628

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO PEREIRA DE PAULA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO CORTINA CAMPOPIANO

Vistos.

Consta da denúncia que os réus, PAULO PEREIRA DE PAULA e ERICK DOS SANTOS SILVA, em hora e local descritos na inicial acusatória, traziam consigo e guardavam, para consumo de terceiros, a substância entorpecente mencionada na peça inaugural. Em razão dos fatos, foram denunciados como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Denúncia recebida à fl. 172. Audiência de instrução colhida por meio audiovisual.

DECIDO.

1. Sem preliminares. No mérito, a ação é procedente.

A materialidade é expressa pelo laudo toxicológico de fls. 205/207, bem como toda a prova oral produzida.

Ouvidos em juízo, os policiais civis reafirmaram, sem inovação substancial, o contido nos depoimentos administrativos de fls. 02/03, aos quais me reporto.

Interrogado em juízo, o réu Paulo, disse que havia ido comprar drogas; que não conhecia Erick; que não conhecia os policiais; que a sacola foi encontrada no meio do mato; que várias pessoas saíram correndo.

O réu Erick, por sua vez, afirmou que havia ido ao local comprar drogas; que deu uma nota de R\$ 50,00 para Paulo, que estava vendendo os narcóticos; que recebeu uma porção de cocaína, além de R\$ 40,00 de troco; que quando os policiais chegaram jogou a cocaína ao solo; que não conhecia os policiais; que está preso preventivamente por tráfico de drogas em outro processo.

A condenação afigura-se de rigor.

Isso porque em momento algum os réus afirmaram ter tido desavença anterior com os servidores da ordem realizadores da prisão que, em tese, justificasse desejo de vingança por parte destes. De outra sorte, também não informaram ter recebido pedido ou exigência de vantagem indevida deles. Assim, inexistente fundamento a esvaziar a confiabilidade dos depoimentos dos respeitáveis policiais civis.

Visível, ainda, a contradição nas palavras dos réus, já que Erick noticiou ter adquirido entorpecentes de Paulo, o qual deu versão totalmente diversa.

Especificamente quanto à tese de Erick, vale destacar que não foram apreendidas drogas no chão ou qualquer nota de R\$ 50,00, tratando-se de alegação, também por isso, sem qualquer respaldo nas provas produzidas.

Irrelevante a divergência na prova vocal apontada pela defesa técnica do réu Paulo, tendo um dos policiais dito que a sacola, no momento da abordagem, estaria nas mãos do réu, enquanto o seu colega afirmou que o recipiente em tela estaria perto do aludido pelo réu. Trata-se de diferença de pouquíssima monta, plenamente compreensível em razão do tempo decorrido entre os fatos e a audiência e diante da pletora de casos muito parecidos com este na rotina policial. De qualquer modo, não é demasiado lembrar que antes da abordagem propriamente dita o réu foi visto manuseando a sobredita sacola durante as transações anteriores, circunstância afirmada em uníssono pelos policiais.

2. Passo a dosar as penas, iniciando pelo réu Paulo.

Na primeira fase, existe circunstância judicial desfavorável, a recomendar o aumento da pena-base.

A jurisprudência do STF já se solidificou no sentido de a quantidade de entorpecente servir, dependendo do caso concreto, como fundamento ao aumento da pena-base, quando da aferição das circunstâncias do crime. Nesse sentido: HC 78.383-5; DJ 21/05/1999.

Na mesma linha de raciocínio, decisório do Superior Tribunal de Justiça (grifos meus):

“CRIMINAL - HC - Tráfico de entorpecentes - Dosimetria - Pena-base - Circunstâncias judiciais devidamente analisadas - Consideração de peculiaridades concretas do delito - Quantidade da droga apreendida - Objetivo de lucro fácil - Prejuízo à saúde pública - Exasperação fundamentadamente procedida - Observância do método trifásico - Inexistência de constrangimento ilegal - Confissão espontânea - Não-ocorrência - Condenação com base nas demais provas dos autos - Associação eventual para o tráfico - Majoração acima do mínimo legal com fundamento na quantidade da droga apreendida - Bis in idem - Constrangimento ilegal evidenciado - Progressão de

regime - Delito hediondo - Impossibilidade - Lei nº 8.072/90 - Constitucionalidade - Inexistência de ofensa ao princípio da individualização da pena - Ordem parcialmente concedida.

...

II. O magistrado singular, para a aplicação da pena-base, procedeu ao correto exame das circunstâncias judiciais, considerando as peculiaridades concretas do delito de tráfico de drogas em questão, tais como a quantidade da droga apreendida, o objetivo de lucro fácil e as graves consequências à saúde pública, aspectos caracterizadores da referida prática criminosa que não são inerentes ao tipo penal, ao contrário do que sustenta a impetração.

..."

(STJ - HC nº 46.791/SC - 5ª T. - Rel. Ministro Gilson Dipp - J. 03.11.2005 - DJ 21.11.2005).

Na presente hipótese, o réu portava 230 porções de drogas diversas, quantidade acima do patamar ordinário inerente ao delito, recomendando incremento nesta etapa, em homenagem ao princípio da individualização da pena.

Sanção aumentada em 1/6, fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão.

Na segunda fase, conforme fls. 32/38 e 40/41, o réu possui duas condenações anteriores definitivas, pelos crimes de roubo e tráfico de drogas. A execução nº 1 estava prevista para ser encerrada pelo cumprimento em 07/09/2022. A execução nº 2, para 28/10/2019. Ambas, portanto, aptas a gerar reincidência. Trata-se o réu, pois, de multirreincidente e reincidente específico.

O reproche deve ser rigoroso, pois tudo indica, dada a renitência criminosa específica em delitos graves, que o réu é indivíduo que faz do crime o seu meio de vida, o seu leitmotiv, não se tratando de um evento isolado. Agravo a admoestação no patamar de 1/3, impondo-a em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão.

Por fim, a minorante prevista no art. 33, par. 4º da lei de regência sequer pode ser vislumbrada, à luz da reincidência.

Concernente à pena de multa, na forma dos arts. 42 e 43 da Lei de Drogas, em primeiro lugar, em simetria com a pena corporal aplicada, fixo o número de dias-multa em 777. Em um segundo momento, atento à condição financeira do réu, estipulo o dia-multa em seu valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo), à míngua de maiores informações.

Passo a deliberar sobre o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e sobre a possibilidade de sua substituição por reprimenda restritiva de direitos.

O regime inicial expiatório será o fechado, em razão da reincidência dolosa específica.

Inviável falar em substituição por pena restritiva de direitos, em decorrência da reincidência dolosa e da quantidade de pena privativa de liberdade aplicada.

Ao réu Erick.

Na primeira fase, existe circunstância judicial desfavorável, a recomendar o aumento da pena-base.

A jurisprudência do STF já se solidificou no sentido de a quantidade de entorpecente servir, dependendo do caso concreto, como fundamento ao aumento da pena-base, quando da aferição das circunstâncias do crime. Nesse sentido: HC 78.383-5; DJ 21/05/1999.

Na mesma linha de raciocínio, decisório do Superior Tribunal de Justiça (grifos meus):

"CRIMINAL - HC - Tráfico de entorpecentes - Dosimetria - Pena-base - Circunstâncias judiciais devidamente analisadas - Consideração de peculiaridades concretas do delito - Quantidade da droga apreendida - Objetivo de lucro fácil - Prejuízo à saúde pública - Exasperação fundamentadamente procedida - Observância do método trifásico - Inexistência de constrangimento ilegal - Confissão espontânea - Não-ocorrência - Condenação com base nas demais provas dos autos - Associação eventual para o tráfico - Majoração acima do mínimo legal com fundamento na quantidade da droga apreendida - Bis in idem - Constrangimento ilegal evidenciado - Progressão de regime - Delito hediondo - Impossibilidade - Lei nº 8.072/90 - Constitucionalidade - Inexistência de ofensa ao princípio da individualização da pena - Ordem parcialmente concedida.

...

II. O magistrado singular, para a aplicação da pena-base, procedeu ao correto exame das circunstâncias judiciais, considerando as peculiaridades concretas do delito de tráfico de drogas em questão, tais como a quantidade da droga apreendida, o objetivo de lucro fácil e as graves consequências à saúde pública, aspectos caracterizadores da referida prática criminosa que não são inerentes ao tipo penal, ao contrário do que sustenta a impetração.

..."

(STJ - HC nº 46.791/SC - 5ª T. - Rel. Ministro Gilson Dipp - J. 03.11.2005 - DJ 21.11.2005).

Na presente hipótese, o réu portava 230 porções de drogas diversas, quantidade acima do patamar ordinário inerente ao delito, recomendando incremento nesta etapa, em homenagem ao princípio da individualização da pena.

Sanção aumentada em 1/6, fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão.

Na segunda etapa, nada a considerar.

Por fim, o réu não faz jus à minorante do art. 33, par. 4º, da Lei de Drogas.

Enfatizo que o STJ entende possível a denegação da minorante se pendentes contra o réu inquéritos e processos criminais em curso, malgrado ausente condenação definitiva, vez que indicativos da dedicação a atividades criminosas. Segue a ementa (grifei):

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENALIDADE. ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO INQUÉRITOS E/OU AÇÕES PENALIS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - O benefício legal previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 pressupõe o preenchimento pelo Réu de todos os requisitos cumulativamente, sendo eles: i) primariedade; ii) bons antecedentes; iii) não dedicação em atividade criminosa; iv) não integrar organização criminosa.

II - O crime de tráfico de drogas deve ser analisado sempre com observância ao mandamento constitucional de criminalização previsto no artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal, uma vez que se trata de determinação do constituinte originário para maior reprimenda ao delito, atendendo, assim, ao princípio da vedação de proteção deficiente.

III - Assim, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. IV - In casu, o Tribunal de Justiça afastou a causa de diminuição de pena mencionada em virtude de o Réu ostentar condenação por tráfico de drogas

não transitada em julgado, considerando que ele se dedica à atividade criminosa por não desempenhar atividade lícita, bem como porque "assim que saiu da cadeia, voltou a praticar o mesmo delito". Embargos de divergência providos para prevalecer o entendimento firmado no acórdão paradigma, restabelecendo o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça". (ERESP 1431091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017)

Na presente hipótese, conforme certidão de fls. 208/209, o réu responde a outro processo por fato idêntico, cometido poucos meses depois da prisão em flagrante pelo delito ora apurado, já tendo sido condenado em primeiro grau de jurisdição. Há indícios concretos, pois, de dedicação habitual ao comércio espúrio.

No mesmo sentido, recente julgado do egrégio TJSP:

"... Na terceira fase, a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, não pode incidir. Com efeito, embora tecnicamente primário, a prova dos autos não deixou dúvida quanto à sua dedicação à atividade criminosa... Demais disso, registra uma condenação por tráfico (em Primeiro Grau, fls. 34), circunstância que, embora não seja apta a caracterizar Maus antecedentes nem a reincidência, reforça a convicção de que se dedicava à atividade criminosa, que persiste em obter lucro fácil por meio do comércio espúrio..." (TJSP; Apelação Criminal 1501835-21.2019.8.26.0571; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/06/2022; Data de Registro: 14/06/2022)

Afastada a benesse.

Concernente à pena de multa, na forma dos arts. 42 e 43 da Lei de Drogas, em primeiro lugar, em simetria com a pena corporal aplicada, fixo o número de dias-multa em 583. Em um segundo momento, atento à condição financeira do réu, estipulo o dia-multa em seu valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo), à míngua de maiores informações.

Passo a deliberar sobre o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade e sobre a possibilidade de sua substituição por reprimenda restritiva de direitos.

Mudando o meu posicionamento, passei a entender viável a imposição legal de início de cumprimento de pena em regime inicial fechado, independentemente de singularidades do caso concreto. Explico.

É verdade que o STF já considerou inconstitucional a determinação de regime inicial obrigatoriamente fechado (art. 2º, par. 1º, da Lei de Crimes Hediondos), cabendo ao juiz do caso o estabelecimento do regime a partir da aferição dos elementos concretos do processo (HC 111840/ES, rel. Min. Dias Toffoli, 27.6.2012).

Todavia, não há decisão em tal sentido prolatada em sede de controle concentrado de constitucionalidade; logo, inexistente efeito vinculante a manietar os demais órgãos judiciários.

Ademais, o próprio STF, ao que parece, vem vacilando sobre o tema.

É que a 1ª Turma daquela Corte Constitucional reputou constitucional o art. 1º, par. 7º, da Lei n. 9455/97, que estabelece, como regra, cumprimento de pena em regime inicial fechado para os condenados pelo crime de tortura (HC 123316/SE, rel. Min. Marco Aurélio, 9.6.2015).

Vale ressaltar que a tortura e o tráfico de entorpecentes receberam o mesmo tratamento pelo constituinte originário (art. 5º, XLIII, CF/88).

Não há qualquer razão, portanto, para conferir ao condenado por tráfico tratamento mais benevolente do que o concedido ao apenado pelo delito de tortura -- sendo conveniente lembrar, aliás, que o crime de tortura, salvo quando resulte em morte da vítima, possui pena-base inferior ao de tráfico.

Enfim, deve ser homenageado o art. 2º, par. 1º, da Lei de Crimes Hediondos.

De qualquer forma, ainda que fosse deixado de lado o dispositivo supra, é fato que qualquer outro regime não fará frente aos objetivos da prevenção e reprovação do crime (art. 59, caput, parte final, CP), em vista da gravidade em concreto do delito praticado, o que autorizou, destarte, exasperação na primeira fase e negativa de diminuição na última do trajeto censório.

Inviável falar em substituição por pena restritiva de direitos, em decorrência da quantidade de pena privativa de liberdade aplicada.

3. Ante o exposto:

A) declaro o réu PAULO PEREIRA DE PAULA incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e o condeno à pena privativa de liberdade de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 777 dias-multa cada, com cada dia-multa montando em seu valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo).

B) declaro o réu ERICK DOS SANTOS SILVA incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e o condeno à pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 583 dias-multa cada, com cada dia-multa montando em seu valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo).

4. Determino, ainda, o perdimento do numerário apreendido, ante as fortes evidências de se tratar de dinheiro fruto da traficância espúria (art. 63, par. 1º, Lei de Drogas). Oficie-se.

5. O réu Paulo, que respondeu ao feito preso, assim deve permanecer, pois seu acautelamento anterior, por óbvio, foi revigorado com a prolação desta sentença condenatória que o exprobrou a iniciar a pena em regime fechado.

Seria um manifesto contrassenso, aliás, que respondendo ao feito preso o réu condenado a regime inicial diverso do aberto pudesse ser posto em liberdade após a sentença recorrível. Outro não é o posicionamento do STJ em hipóteses do gênero:

"O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade"

(AgRg no HC 657.744/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021).

6. Após o trânsito em julgado desta, lancem-se os nomes dos apenados no rol dos culpados.

7. Custas na forma da legislação estadual.

8. Existindo bens apreendidos, autorizo a devolução aos legítimos proprietários; se ausentes ou desconhecidos, proceda-se na forma do art. 123 do CPP.

9. Havendo advogados nomeados, expeçam-se as certidões de praxe no momento

oportuno.

P.R.I.C.

Itapecerica da Serra, 18 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA